

1510937-94.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Aristoteles de Alencar Sampaio

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... reconhecer que a droga apreendida destinava-se ao tráfico e não ao consumo próprio, pois tais circunstâncias, à falta de outros elementos, são incompatíveis com o mero consumo próprio.

Caracterizado o crime de tráfico, a condenação do acusado Isaac é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

A pena-base do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas será ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

1ª Vara Criminal

1510937-94.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1510937-94.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAAC DE MENESES COSTA e outro

Vistos.

ISAAC DE MENESES COSTA e GUILHERME VÍTOR FERREIRA DA SILVA como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06, porque, em 13/05/2021, na Rua Jéssica Ribeiro Akimoto, 61, nesta cidade, teriam trazido consigo e guardado, para fins de tráfico, substância entorpecente que determina dependência química e física, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Os réus foram citados e apresentaram defesa preliminar, tendo a denúncia sido recebida.

Durante a audiência de instrução foi produzida prova oral, tendo sido os réus interrogados.

As partes apresentaram suas alegações finais, tendo o Ministério Público requerido a condenação dos réus pelo crime descrito na denúncia, posto entender comprovadas a materialidade delitiva e a autoria; a defesa, por sua vez, sustentou nulidade processual, e, no mérito, pugnou pela absolvição do réu pela insuficiência probatória e, de forma subsidiária, pela desclassificação do delito para uso de drogas.

Após, vieram os autos conclusos.

Relatados. D E C I D O:

Rejeito a matéria preliminar.

Aduz a defesa que ocorreu nulidade no inquérito policial em razão de não ter sido observada a incomunicabilidade dos guardas municipais ouvidos quando da prisão em flagrante, aduzindo, ainda, que esta nulidade contamina todo o processo.

Todavia, ainda que possa ter ocorrido quando da oitiva na fase inquisitiva a violação à incomunicabilidade, tem-se que é pacífico que eventual irregularidade em inquérito policial não contamina o processo, como reconhece o C. Superior Tribunal de Justiça: "o entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não maculam a ação penal dele derivada (STJ - HC 285.952/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 25/10/2017). Neste sentido, EDUARDO ESPÍNOLA FILHO já assentava que "o inquérito não é parte integrante do processo criminal, mas mero elemento de instrução da Promotoria Pública, ou da parte privada, na fundamentação da denúncia ou da queixa. E, por isso, não importa na consequência de invalidar, anulando-o, o processo criminal, a circunstância de se terem realizado, no inquérito, diligência ou quaisquer atos sem respeitar as formalidades legais, ou mesmo contrariando expressas determinações da lei. O fato só terá o resultado de retirar o valor probante do ato ou diligência assim viciados, o qual, entretanto, o juiz mandará, por sanar-lhe a falta, repetir, sempre que isso for realizável. Somente na hipótese de tratar-se de peça legalmente declarada indispensável ao processo e cuja falta não haja meio de suprir, a nulidade dêse poderá ser pronunciada" Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, vol. Editor Borsoi, 1965, pág. 260).

E tal independência da irregularidade ocorrida no inquérito é mais evidenciada quando se verifica que em juízo foi observada a incomunicabilidade das testemunhas, assegurando-se, pois, o atendimento a todas as prescrições legais, inexistindo, pois, qualquer prejuízo aos acusados.

A ação penal merece prosperar

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de fls. 12/13, em que se descreve o material apreendido na posse do réu. Por outro lado, o exame químico-toxicológico revelou consistir a substância apreendida em entorpecente, concluindo, pois, por sua toxicidade e potencialidade para causar dependência (fls. 376/377). Assim, a materialidade delitiva foi comprovada.

Análise a autoria delitiva.

Com efeito, o guarda VALDEMIR FRANCISCO DE PAULA JÚNIOR disse em juízo que estava em patrulhamento em local já conhecido pela prática de tráfico de drogas, quando avistou os réus, que ao verem a viatura dispensaram uma sacola ao solo e correram sobre os muros de algumas casas. Os réus foram perseguidos e abordados, nada foi encontrado em poder deles, mas as drogas foram localizadas na sacola dispensada pelos réus durante a fuga. Uma sacola foi localizada na primeira casa onde entraram e onde estava Isaac foi encontrada uma sacola com drogas e foi encontrada outra sacola com drogas no local em que eles estavam antes da chegada da polícia. Não soube identificar quem dispensou as drogas. Não viu nenhum ato de comércio por parte dos acusados. Havia vários tipos de drogas. O acusado Isaac não foi agredido por nenhum dos guardas municipais. Disse que ambos confessaram no local a prática do tráfico.

No mesmo sentido foram as declarações do guarda municipal EDNELSON PEIXOTO, que acrescentou que foi o réu Guilherme Vitor quem dispensou a droga durante a fuga. Não conhecia dos acusados antes dos fatos. Disse que narrou os fatos na delegacia de polícia junto com seu parceiro. A motivação para a abordagem foi a fuga dos acusados e a dispensa da sacola. Isaac foi detido na primeira quadra e o correu há mais quadras no local. Foi necessário usar algemas em razão da fuga dos agentes. Eles não agrediram os guardas.

Neste passo, como já declarou o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus depoimentos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem em defesa coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286), e, ainda, "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente "(RT 614/275). Além disso, inexistente qualquer razão comprovada e justificada para retirar a credibilidade destes depoimentos policiais, os quais se mantêm válidos e aptos a sustentarem decreto condenatório.

Note-se que as alegações de que houve agressão contra um dos réus ou pedido de propina somente poderiam ser reconhecidas em juízo acaso houvesse outras provas neste sentido, o que no caso dos autos não ocorreu, restando, pois, isolada esta versão ao menos neste momento processual, devendo ser analisada nos autos que apurarão a alegada agressão, o que já foi determinado (fls. 204).

ROGÉRIO GOMES DE SOUZA disse em juízo que conhecia o réu Guilherme, pois são vizinhos, conhece toda a família dele, sabe que ele sempre foi esforçado e trabalhador, e uma pessoa boa. Sabe que Guilherme é usuário de drogas.

O réu ISAAC DE MENEZES COSTA confessou em juízo a prática do tráfico de drogas no dia dos fatos. Disse que estava com as drogas, que eram destinadas à venda, mas em menor quantidade do que aquele apreendida pelos guardas. Acrescentou que o réu Guilherme estava no local para adquirir drogas. Disse que foi agredido pelos guardas municipais e que eles pediram propina.

O réu GUILHERME VITOR FERREIRA DA SILVA, por sua vez, negou a autoria do crime em juízo. Disse que na ocasião estava no local para adquirir drogas do réu Isaac, e quando os policiais chegaram, se assustou e correu juntamente com o réu Isaac.

O conjunto probatório produzido nos autos indica a prova segura da traficância pelo acusado Isaac. Já em relação ao acusado Guilherme há dúvida, que impõe a sua absolvição.

De fato, pesa contra o acusado Guilherme o fato de ter sido visto pelos guardas municipais junto com o acusado Isaac e ter fugido quando avistou os policiais,

sendo certo que não foi visto pelos guardas realizando nenhum ato de comércio do entorpecente. Por outro lado, o corréu, assumindo a propriedade da droga e a prática do tráfico, afirmou que o réu Guilherme estava apenas comprando a droga, o que possui algum respaldo na oitiva da testemunha apresentada nos autos dando conta dele ser usuário de droga.

É certo que em juízo um dos guardas municipais disse que chegou a ver pelas vestimentas o acusado Guilherme dispensando uma das sacolas de drogas, o que não foi corroborado nem por seu parceiro de farda, que não soube dizer em juízo quem havia dispensado a sacola, nem mesmo pelo relato firmado na fase policial, no qual nada consta sobre a identificação de quem havia dispensado as drogas. E ante essa peculiaridade de não ter sido confirmada nem pelo seu parceiro de farda, nem pelo contido no inquérito policial, tem sua declaração neste aspecto reduzida em sua força probatória.

Assim, embora existam indícios de autoria do delito, não se pode descartar a possibilidade da veracidade das declarações do acusado Guilherme de ser apenas um usuário, declaração esta que foi respaldada pelo próprio corréu, razão pela qual a sua absolvição é determinada pelo princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Já em relação ao acusado Isaac, pela convergência dos depoimentos dos guardas municipais em relação à parcial confissão deste acusado, autoriza o reconhecimento de que a droga apreendida estava na posse deste acusado, tanto que foi apreendida próxima do local em que ele estava fugindo, impondo-se, ainda, reconhecer que toda a droga apreendida deve a ele ser imputada, ante a sua apreensão nos locais em que esteve fugindo o acusado, restando apenas a análise da destinação do entorpecente.

Tendo em vista a elevada quantidade de droga e sua forma de acondicionamento, aproximadamente 129 porções de cocaína, 100 porções de "crack" e 250 porções de maconha, é forçoso reconhecer que a droga apreendida destinava-se ao tráfico e não ao consumo próprio, pois tais circunstâncias, à falta de outros elementos, são incompatíveis com o mero consumo próprio.

Caracterizado o crime de tráfico, a condenação do acusado Isaac é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

A pena-base do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas será fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a especial circunstância de se tratar parte da droga apreendida de cocaína e parte em sua forma mais tóxica de "crack", entorpecente este que causa dependência química, vulnerando com maior intensidade a saúde pública pelos deletérios efeitos à integridade física dos consumidores da droga, havendo, assim, maior desvalor da conduta do acusado quando comparado, por exemplo, com a conduta relativas a outras drogas, como por exemplo, o cloreto de etila, impondo-se a exasperação da pena. A jurisprudência corrobora este entendimento: "A natureza e a quantidade da droga apreendida, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, são circunstâncias que, por si só, justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal" (STJ - HC n.º 165.387/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 8-2-2011, DJe 21-2-2011). Fixo, em razão destas circunstâncias, a pena-base em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso legal.

Pela menoridade e confissão do acusado Isaac, reduzo a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Sobre o redutor do art. 33, §4o, da Lei de DROGAS, tem-se que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação do índice de redução ou até mesmo impedir a sua aplicação

da causa de diminuição de pena (STJ - AgRg no HC 562.200/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

In casu, porque primário, reduzo a pena em 1/6 em face do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, redução esta abaixo do patamar máximo, tendo em vista a natureza da droga apreendida – cocaína/crack – e que vulnera com maior intensidade a saúde pública e sua quantidade. Perfaz, pois, a reprimenda 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida, e, ainda, a circunstância do crime de tráfico de drogas ser por demais grave, sendo certo que atualmente é o crime que mais vêm gerando violência no país, impondo-se reconhecer a necessidade da fixação do regime de cumprimento de pena mais rigoroso.

Em atendimento ao art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, consigna-se que o tempo de prisão provisória em nada altera a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, ante a ausência de prova acerca dos requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios legais, que deverão ser buscados junto ao juiz das execuções criminais (art. 66, III, b, da Lei de Execuções Penais).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para:

a) ABSOLVER GUILHERME VITOR FERREIRA DA SILVA da acusação descrita na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura;

b) CONDENAR ISAAC DE MENESES COSTA à pena cada um de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 416 dias-multa, no mínimo unitário, por infração ao art. 33, §4o, da Lei nº 11.343/06.

Não poderá o réu Isaac recorrer em liberdade porquanto respondeu ao processo no cárcere, subsistindo, ainda, os requisitos ensejadores da prisão decorrente do flagrante a fim de garantir a ordem pública contra novos atentados à saúde pública.

A proibição ao direito de recorrer em liberdade aos réus que respondem presos à instrução vem sufragada pela doutrina como se depreende da lição do jurista Guilherme Nucci: “Réu que aguardou preso a instrução: deve continuar detido, após a prolação da sentença condenatória, mormente se foi aplicado o regime fechado ou o semi-aberto. Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação.”

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não pode ser acolhida, pois, além da quantidade de pena cominada, em se tratando de delito gerador de violência social e familiar, e pelo princípio da suficiência, incide o entendimento jurisprudencial pelo qual: “como se trata de crime de tráfico ilícito de drogas, cuja conduta enseja especial censurabilidade pelos efeitos nefastos na saúde dos usuários e na Saúde Pública de um modo geral, além de servir de elemento propagador e incrementador de toda uma ordem criminoso, que tantos malefícios vêm trazendo à nossa Sociedade, não concedo o regime aberto ou a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, que não bastariam à reprovação do crime.”(TJSP - Apelação nº 0021376-71.2012.8.26.0309 - Jundiaí - Rel. Des. Alex Zilevoski, j. 8.4.13).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Recomende-se o acusado no local em que se encontra recolhido.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Declaro a perda em favor da União dos bens apreendidos nos autos, pois vinculados ao tráfico de drogas.

P.R.I.

Sumare, 11 de abril de 2022.

ARISTÓTELES DE ALENCAR SAMPAIO
Juiz de Direito